

1500039-27.2022.8.26.0591

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: VANDICKSON SOARES EMIDIO

Comarca: Tupi Paulista

Foro: Foro de Tupi Paulista

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 09/05/2022

... REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. REINCIDÊNCIA. ÓBICE LEGAL. BIS IN IDEM NÃO CONFIGURADO. 1. O entendimento desta Corte Superior é no sentido de que a reincidência, ainda que por delito de natureza diversa, constitui óbice legal à concessão da minorante do tráfico privilegiado, consoante previsto no art. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Tupi Paulista

Foro de Tupi Paulista

1ª Vara

Rua Tiradentes, 877, Tupi Paulista-SP - cep 17930-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500039-27.2022.8.26.0591 - lauda  
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500039-27.2022.8.26.0591

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2033611/2022 - DEL.SEC.DRACENA PLANTÃO, 22841475 -

DEL.SEC.DRACENA PLANTÃO, 2033611 - DEL.POL.TUPI PAULISTA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MAILSON DE SOUZA TREVISAN

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). VANDICKSON SOARES EMIDIO

Vistos.

O Ministério Público, por intermédio de seu Representante Legal em exercício neste juízo e no uso de suas atribuições legais, com base no incluso auto de prisão em flagrante, ofereceu denúncia em face de MAILSON DE SOUZA TREVISAN, devidamente qualificado nos autos, dando-o como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006, pela prática dos fatos delituosos narrados na peça vestibular, nos seguintes termos:

Consta da denúncia que no dia 5 de fevereiro de 2022, por volta das 14:10h, na rua Doutor Amauri C. Araújo, nº 175, Jardim Petrópolis, nesta cidade e Comarca, o réu trazia consigo 36,84g (trinta e seis gramas e oitenta e quatro decigramas) da substância entorpecente Tetrahydrocannabinol, para fins de tráfico, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo o órgão ministerial, o réu trazia consigo o entorpecente no interior de uma

sacola plástica, pretendendo comercializa-lo em um bar localizado próximo a um campo de futebol. Contudo, ao avistar a aproximação de policiais militares e com o intuito de evitar sua prisão em flagrante, o réu dispensou a droga.

Ocorre que os policiais já possuíam informações sobre a traficância exercida pelo réu naquele local, o que ensejou a varredura nas imediações. Assim, localizaram a droga já fragmentada, sendo confirmado por uma testemunha ocular que a sacola era portada pelo réu instantes antes da ação policial. A testemunha teria informado, ainda, que o acusado já havia vendido uma porção do entorpecente a um desconhecido que acabara de deixar o local. Em revista pessoal, foi apreendida uma nota de R\$: 10,00 (dez reais).

Na data subsequente aos fatos, fora convertida a prisão em flagrante do acusado em prisão preventiva (fls. 81/85).

Laudo pericial de exame químico de entorpecente acostado às fls. 128/130.

O réu foi regularmente notificado e ofereceu defesa prévia (fls.136/137).

A denúncia foi recebida em 7 de março de 2022 (fls. 143/145), o réu foi regularmente citado (fl. 164) e houve a designação de audiência de instrução, interrogatório debates e julgamento.

Prosseguiu-se, então, à fase instrutória, momento em que foram ouvidas testemunhas, sendo o réu interrogado ao final (fls. 171/175).

Na fase do artigo 402 do Código de Processo Penal, as partes nada requereram.

Em alegações finais, o Ministério Público pleiteou a condenação do réu, eis que comprovadas a materialidade e autoria delitiva.

A defesa, por sua vez, pugnou pela desclassificação do tipo penal em razão da ausência de provas para subsumir a conduta do réu ao delito de tráfico, uma vez que este é dependente químico e adquiriu as drogas para consumo pessoal.

Subsidiariamente, pleiteou pelo arbitramento da pena no patamar mínimo legal, além da concessão do direito de recorrer da sentença em liberdade.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A pretensão punitiva é procedente.

Trata-se de ação penal pública incondicionada, objetivando apurar a responsabilidade de MAILSON DE SOUZA TREVISAN pela prática do fato delituoso disposto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006.

A materialidade do delito de tráfico de entorpecentes está comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 04/05), boletim de ocorrência (fls. 16/18), laudo de constatação preliminar (fls. 27/31), auto de exibição e apreensão (fls. 21/22), e laudo toxicológico definitivo (fls. 128/130), que atestou que a substância encontrada se tratava de tetrahidrocannabidol, de uso proscrito no Brasil.

A autoria, por seu turno, é inconteste e atribuída ao acusado.

Ouvida em juízo, a testemunha Jamil Guilhermino de Brito, policial compromissado, disse que estava em serviço com o policial Otávio quando recebeu informações sobre a prática de tráfico de drogas por Mailson nas proximidades de um campo de futebol localizado no Jardim Petrópolis. Assim, como já tinham outras informações sobre a traficância pelo réu em bares da cidade, deslocaram-se até o local indicado na delação. Ali, encontraram Mailson e Alexandre, sendo realizada busca pessoal em ambos, mas localizaram apenas R\$: 10,00 (dez reais) na posse do primeiro. No entanto, durante a abordagem, Alexandre relatou que Mailson teria acabado de arremessar uma sacola que continha entorpecentes em seu interior, o que ensejou a ação policial nas imediações, localizando-a; constataram, então, que se tratava de porções de "maconha". Inicialmente, Mailson teria negado a propriedade do entorpecente, mas depois confessou e alegou que a droga era destinada ao consumo pessoal. Diante da conduta, o acusado foi conduzido até a delegacia de polícia local, ocasião em que o delegado ratificou a prisão em flagrante. Inquirido pela acusação, respondeu que as denúncias pretéritas se referiam a Mailson, o qual já era conhecido nos meios policiais por praticar o comércio de drogas na cidade; que Alexandre afirmou no momento da abordagem que Mailson teria oferecido drogas às pessoas naquela oportunidade, mas que as delações sobre a traficância pelo réu em bares são de outras pessoas. Indagado pela defesa, respondeu que as drogas estavam armazenadas numa sacola plástica em vários fragmentos, uns maiores e outros

menores, mas todos acondicionados no mesmo local; que não havia outra embalagem, apenas a sacola.

A testemunha Diogo Otávio P. Duarte, policial compromissado, disse que estava em patrulhamento na data dos fatos quando recebeu a informação de que Mailson estaria comercializando entorpecentes no bairro Petrópolis, próximo a um campo de futebol. Diante de denúncias recebidas durante aquela semana sobre os mesmos fatos, dirigiram-se até o local, ocasião em que abordaram Mailson e a testemunha Alexandre. Realizada busca pessoal em ambos, localizaram apenas a quantia de R\$: 10,00 (dez reais) na posse de Mailson, ao passo que com Alexandre nada de ilícito foi encontrado. Durante a entrevista, Alexandre informou que Mailson estava comercializando entorpecentes naquele local, mas que dispensou a sacola plástica com as drogas assim que visualizou a chegada da viatura. Ao ser questionado, primeiramente Mailson negou; contudo, ao ser realizada vistoria nas imediações, localizaram a referida sacola com os entorpecentes, razão pela qual indagou novamente Mailson que, desta vez, confessou a propriedade, mas alegou que eram destinados ao consumo pessoal. Diante da quantidade de drogas, conduziram o acusado até a delegacia de polícia, ocasião em que o delegado ratificou a prisão em flagrante. Inquirido pela acusação, confirmou o fato de que Alexandre teria informado que Mailson ofereceu drogas às pessoas que frequentavam o local, mas que não disse nada a respeito da concretização de alguma venda. Indagado pela defesa, respondeu que a droga estava fragmentada em alguns pedaços pequenos e outros maiores, os quais estavam acondicionados na mesma sacola; que com Mailson foi localizado apenas R\$: 10,00 (dez reais), e o entorpecente foi encontrado na sacola. Interrogado, o réu confessou a propriedade da droga, mas afirmou que era destinada ao consumo pessoal, pois é dependente desde os 15 (quinze) anos de idade. Na data dos fatos, argumentou que havia acabado de sair de seu trabalho quando foi até o bar adquirir os entorpecentes. Como remuneração, teria recebido R\$: 100,00 (cem reais), mas utilizou R\$: 90,00 (noventa reais) na compra das drogas, por isso estava na posse de R\$: 10,00 (dez reais). Indagado, respondeu que trabalhava como servente de pedreiro, e que respondeu a processo por tráfico de drogas nesta Comarca.

Pois bem.

Por tudo quanto exarado, tem-se por absolutamente incontestes a configuração dos elementos objetivos, subjetivos e normativos do tipo em comento, sendo que a versão apresentada pelo acusado é dissonante da realidade fática comprovada nos autos. Por seu turno, as versões das testemunhas militares sobre os fatos são uníssonas e vão ao encontro dos elementos informativos que dão suporte à acusação. Não há porquê desconfiar da palavra dos policiais militares que, na qualidade de agentes públicos, possuem fé pública, gozando a presunção juris tantum de veracidade, qualidade essa que não foi afastada pela louvável defesa; longe disso, o teor dos depoimentos foi confirmado pelo próprio réu ao assumir a propriedade da droga, apenas divergindo quanto à sua destinação.

E, neste ponto, a forma fragmentada em que foi encontrado o entorpecente infirma a credibilidade da narrativa do réu, ao passo em que reforça o teor do depoimento prestado em solo policial por Alexandre (fl. 10).

Malgrado essa testemunha não tenha sido localizada para prestar seu depoimento em juízo, suas declarações foram confirmadas pelas testemunhas ouvidas em audiência, ou seja, a prova não deriva exclusivamente do depoimento prestado em solo policial, uma vez que, submetida à instrução probatória, foi ratificada em juízo sob o crivo do contraditório. Nesse sentido, cumpre transcrever a ementa que reflete o entendimento do C. STJ sobre o tema:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO. OFENSA A DISPOSITIVO INCONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. PROVA PRODUZIDA NO INQUÉRITO POLICIAL E CONFIRMADA EM JUÍZO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A via especial é imprópria para o conhecimento de ofensa a dispositivos constitucionais. 2. A prova utilizada para a condenação não deriva exclusivamente do inquérito policial, mas das provas que foram ratificadas em juízo sob o crivo do contraditório. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no AREsp: 917530 ES 2016/0138491-2, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 07/12/2017, T5 - Quinta Turma, Data de

Publicação: DJe 15/12/2017) - grifei.

Logo, o que era apenas prova indiciária tornou-se inequívoca ao ser confirmada em juízo - o que dá suporte ao decreto condenatório -, uma vez que a prova oral produzida demonstrou de forma iniludível que o entorpecente apreendido sob o domínio do acusado era destinado ao consumo de terceiros, notadamente diante das delações pretéritas e da forma fragmentada usualmente utilizada para facilitar a alienação.

No mais, é imperiosa a necessidade de o julgador estar sempre atento e dedicado às teses defensórias, no entanto, no caso em análise, a versão não pode ser aceita diante do óbvio manifesto que representa sua irreabilidade.

Como já pontuado, a tese de que os entorpecentes foram adquiridos para consumo pessoal esmaece quando cotejada com os demais elementos probatórios, sobretudo quando verificado que também recai sobre o réu delações de traficância praticada habitualmente nos bares deste município.

Existe um nexo íntimo entre o ônus de provar e o ônus de alegar, de modo que, estando as partes em condição de igualdade, alegar e não provar é o mesmo que nada alegar. Dessa forma, não há qualquer elemento indicativo que pudesse infirmar a dinâmica dos fatos descritos na denúncia, a qual foi confirmada pelas provas produzidas no decorrer da ação penal.

Diante desse cenário, verifico que os elementos objetivos, subjetivos e normativos do tipo estão tranquilamente comprovados nos autos, mormente porque "indícios múltiplos, concatenados e impregnados de elementos positivos de credibilidade são suficientes para dar base a uma decisão condenatória, máxime quando excluem qualquer hipótese favorável ao acusado" (MIRABETE, Júlio F., in Processo Penal - 17ª ed. São Paulo: Atlas, 2005, p. 344).

Destarte, o conjunto probatório é suficientemente harmônico e coeso a ponto de legitimar o decreto de condenação pelo crime de tráfico de drogas, não sendo o caso de aplicação do princípio in dubio pro reo. Sob essa ótica, passo a individualizar a pena, de modo fundamentado e seguindo os parâmetros do artigo 68, caput, do Código Penal.

#### DOSIMETRIA DA PENA.

Na primeira fase, analisando-se as circunstâncias judiciais descritas nos artigos 42 da Lei 11343/06 e 59, caput, do Código Penal, as circunstâncias são favoráveis. Isso porque deixo de considerar as condenações pretéritas por posse de drogas para uso pessoal como critério para majorar a pena-base (processos nº 0008377-24.2012.8.26.0168 e 0001899-06.2016.8.26.0638), de acordo com o recente entendimento firmado pelo STF no RHC nº 178.512, o qual vedou qualquer valoração negativa com base em registros anteriores relacionados à infração ao art. 28 da Lei nº 11.343/2006.

Destarte, considerando que tecnicamente o réu não ostenta maus antecedentes criminais e que todos os demais elementos são inerentes ao tipo penal, fixo as penas no patamar mínimo legal de 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria, presente a circunstância agravante da reincidência (art. 61, I, do CP - fls. 62, processo nº 0002985-56.2009.8.26.0638 - art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006). Destarte, impõe-se um agravamento de 1/6 (um sexto) às penas anteriormente fixadas, resultando em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Na terceira fase de cálculo penal, não é o caso de se aplicar o redutor previsto no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06, vez que o acusado é reincidente específico, fator impeditivo para agracia-lo com o benefício. Esclareço que o STJ reconhece que não há violação ao non bis in idem na utilização concomitante da reincidência na segunda e terceira fases da dosimetria da pena. Vejamos a ementa:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. REINCIDÊNCIA. ÓBICE LEGAL. BIS IN IDEM NÃO CONFIGURADO. 1. O entendimento desta Corte Superior é no sentido de que a reincidência, ainda que por delito de natureza diversa, constitui óbice legal à concessão da minorante do tráfico privilegiado, consoante previsto no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, inexistindo bis in idem ante a utilização concomitante na segunda e terceira fases

da dosimetria. Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 1810760/PR, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 09/11/2021, DJe 16/11/2021)

À míngua de qualquer elemento modificador, fixo a pena definitiva em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Não possuindo elementos para averiguar a situação financeira do acusado, fixo o valor de cada dia-multa no mínimo legal de 1/30 (um trigésimo) de salário mínimo vigente à época dos fatos, corrigidos monetariamente pela tabela prática do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo desde a prática delituosa.

Em atenção ao artigo 33, § 2º, do Código Penal, estabeleço o regime inicial fechado para o cumprimento da pena, em razão da reincidência específica, tudo a indicar que o regime mais brando é insuficiente para produzir um efeito dissuasório de sua conduta.

E, pelos mesmos motivos ofertados para fixação do regime, nego ao réu a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, bem como a suspensão condicional da pena, na forma do disposto nos artigos 44 e 77, ambos do Código Penal.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão acusatória para CONDENAR o réu MAILSON DE SOUZA TREVISAN, devidamente qualificado nos autos deste processo crime, como incurso nas penas do artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/2006, a 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, além do pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, no valor mínimo legal de 1/30 (um trigésimo) de salário mínimo vigente à época dos fatos, corrigido monetariamente pela tabela prática do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo desde a prática delituosa.

Considerando as circunstâncias desfavoráveis que demonstram o risco em concreto à ordem pública com sua liberdade, máxime porque agora condenado, nego ao réu o direito de recorrer em liberdade, mantendo incólume os fundamentos da sua prisão preventiva.

Deixo de aplicar o disposto no artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, ante a inexistência de pedido, consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Concedo ao acusado os benefícios da justiça gratuita, razão pela qual deixo de condená-lo nas custas processuais.

Considerando que foram apreendidos nos autos R\$: 10,00 (auto de exibição e apreensão de fls. 21/22), nos moldes do disposto no artigo 91, inciso II, "b" do Código Penal e no artigo 63, § 1º, da lei 11.343/06, declaro, após o trânsito em julgado, o perdimento dos valores (depósito judicial às fls. 126/127) em favor da União e o seu encaminhamento ao Fundo Nacional Antidrogas - FUNAD, em virtude dos fundamentos utilizados nesta sentença.

Oficie-se o órgão competente para o recolhimento dos valores monetários, de acordo com artigo 63, § 1º, da Lei 11.343/06.

Oportunamente, após o trânsito em julgado da presente ação criminal, tomem-se as seguintes providências:

Expeça-se a competente guia de recolhimento, provisória ou definitiva, conforme o caso, bem como carta de guia;

Autorizo a incineração da substância entorpecente, guardando-se apenas o suficiente para eventual contraprova, que, após o trânsito em julgado, também deverá ser incinerada;

Em cumprimento ao disposto no artigo 71, § 2º, do Código Eleitoral, oficie-se o Tribunal Regional Eleitoral deste Estado, comunicando a condenação da ré, com sua devida identificação, acompanhada de fotocópia da presente decisão, para cumprimento do quanto estatuído no artigo 15, inciso III, da Constituição Federal; Oficie-se ao órgão estadual de cadastro de dados sobre antecedentes criminais, fornecendo as informações sobre a condenação da ré.

Intime-se o(a) sentenciado(a) para efetuar o recolhimento do valor da pena da multa, no prazo de 10(dez) dias, sob pena de inscrição em dívida ativa. Decorrido o prazo supra sem que o(a) sentenciado(a) tenha recolhido os valores da multa, certifique a serventia o ocorrido, expeça-se certidão para fins da inscrição em

dívida ativa e comunique-se o ocorrido à Vara de Execuções competente para executar às penas impostas a(o) sentenciado(a);  
A presente sentença servirá, por cópia digitada, como os ofícios necessários, devendo ser instruída com os documentos pertinentes.  
Oportunamente, arquivem-se os autos com as anotações necessárias.  
Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Tupi Paulista, 03 de maio de 2022.

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Vandickson Soares Emídio  
O/A Magistrado/a assina digitalmente, nos termos da lei 11.419/2006, conforme impressão à margem direita.

---